

제62회 변리사 제2차시험 특허법 해설

한빛변리사학원
특허법 강사 일동

시험 보느라 수고 많으셨습니다.

올해 변리사 2차 시험 특허법 문제는 평이했습니다.

배점이 컸던 문제-3의 설문(3)과 문제-4의 설문(1)에서 목차 구성의 어려움이 있었을 수 있지만, 전반적으로는 중요한 쟁점, 판례, 이론이 대부분 출제되었고, 문제 자체가 모호하여 수험생을 혼동하게 하는 경우는 거의 없었습니다.

이런 시험 출제 상황에서는 아는 판례를 누가 더 잘 쓰고, 누가 더 실수를 적게 했으며, 누가 더 논리적으로 사안을 포섭하였는지가 결과를 좌우할 것으로 보입니다.

좋은 결과 있으시기를 바라며, 다시 한 번 수고 많으셨다는 말씀을 드립니다.

한빛변리사학원 특허법 강사 일동

[문제 - 1]

甲은 명칭을 ‘다가 폐렴구균 다당류-단백질 접합체 조성물’로 하는 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 함)의 발명자이자 특허권자이다. 이 사건 특허발명은 13종의 개별 원액을 포함하는 조성물에 관한 물건의 발명 및 13종의 개별 원액을 혼합하여 조성물을 제조하는 공정에 관한 방법의 발명을 청구항으로 포함하고 있다. 조성물은 13종의 개별 원액을 혼합하여 제조되는 공정을 통해 생산된다. 甲의 乙에게 이 사건 특허발명의 독점적 통상실시권을 허락하였다.

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 丙에게 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용실시권을 설정하고 이를 등록하였다. 이와 관련하여, 丙의 전용실시권과 乙의 독점적 통상실시권을 비교 설명하시오. (10점)

(2) 丁은 무단으로 이 사건 특허발명을 실시하고 있다. 乙은 丁을 상대로 특허법상의 손해배상청구권을 행사할 수 있는지 논하시오. (10점)

(3) 戊는 무단으로 13종의 개별 원액을 국내에서 생산하여 이를 甲이 특허출원 및 등록을 하지 않은 A국에 수출하였고, 이를 수입한 A국적의 a는 A국에서 이를 혼합하여 이 사건 특허발명에 속하는 조성물을 생산하였다. 戊가 甲의 특허권을 직접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)

(4) 위 (3)의 지문에서 戊가 甲의 특허권을 간접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)

최근 5년간의 특허법 시험 문제-1 중 가장 평이한 난이도의 문제-1입니다. 대부분 잘 해결하셨을 것으로 판단되지만 사안포섭에서 물건특허와 방법특허에 대해 각각 포섭하는 것을 누락하였는지에 따라 점수 차이가 일부 있을 것으로 보입니다.

(1) 甲은 丙에게 이 사건 특허발명의 실시를 위한 전용실시권을 설정하고 이를 등록하였다. 이와 관련하여, 丙의 전용실시권과 乙의 독점적 통상실시권을 비교 설명하시오. (10점)

I. 설문(1)

1. 문제의 소재 - 의의

- (1) 전용실시권: 특허권자 이외의 자가 특허권자와의 계약에 의해 그 설정된 범위 안에서 업으로서 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다(法100).
- (2) 독점적 통상실시권: 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우의 통상실시권을 말한다(判例).
- (3) 사안의 경우: 丙의 전용실시권과 乙의 독점적 통상실시권을 아래에서 비교한다.

2. 발생

- (1) 전용실시권: 등록이 효력발생요건(法101①(2))
- (2) 독점적 통상실시권: 의사의 합치로 발생(묵시적 합의에 의해서도 가능)
- (3) 사안의 경우

3. 효력

- (1) 전용실시권: 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하고(法100②), 금지청구권(法126), 손해배상청구권(法128), 신용회복청구권(法131)이 인정되며, 고의에 의한 전용 실시권침해는 침해죄를 구성한다(法225).
- (2) 독점적 통상실시권: 계약으로 정한 범위에서 특허발명을 실시할 수 있는 채권적 권리이고, 타인의 침해에 대해 직접적으로 금지청구권, 손해배상청구권 등의 민·형사상 조치를 취할 수는 없다. 이 점이 전용실시권과 차이점이다. 다만 민법상의 손해배상청구권을 행사할 수 있고, 침해금지청구권을 대위행사할 수 있다.
- (3) 사안의 경우

4. 변동

- (1) 전용실시권: 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있는 것이 원칙이나, 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우 동의 없이 이전할 수 있다(法100③).
- (2) 독점적 통상실시권: 실시사업과 함께 이전할 수 있는 것이 원칙이나, 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우 동의 없이 이전할 수 있다(法102). 즉, 전용실시권의 이전의 제한 법리와 동일한 법리가 적용된다.
- (3) 사안의 경우

5. 소멸

- (1) 전용실시권: 특허권에 부수하는 권리이므로 특허권이 소멸하는 경우 소멸한다. 또한 전용실시권

- 의 소멸을 등록하는 경우 소멸하고, 특허권자와 전용실시권자가 일치하는 경우 혼동으로 소멸한다.
- (2) 독점적 통상실시권: 전용실시권과 마찬가지로 특허권에 부수하는 권리이므로 특허권이 소멸하는 경우 소멸한다. 또한, 독점적 통상실시권 계약이 해지 등의 사유로 종료되는 경우 소멸한다(이 경우 등록이 필요하지 않음). 특허권자와 독점적 통상실시권자가 일치하는 경우 혼동으로 소멸한다.
- (3) 사안의 경우

(2) 丁은 무단으로 이 사건 특허발명을 실시하고 있다. 乙은 丁을 상대로 특허법상의 손해배상청구권을 행사할 수 있는지 논하시오. (10점)

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - 침해 성립 여부

- 1) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로(法94①), 유효한 특허권 존속 중, 정당 권원 없는 자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로서 실시하면 침해가 성립한다.
- 2) 丁은 무단으로 이 사건 특허발명을 실시하고 있으므로 특허침해가 성립한다.

2. 특허법상의 손해배상청구권 행사 가부

(1) 제128조제1항

- (2) 사안의 경우: 독점적 통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자가 아니므로, 丁이 고의·과실로 이 사건 특허발명을 침해하더라도 乙이 특허법상의 손해배상청구권을 행사할 수는 없다.

3. 민법상의 손해배상청구권 행사 가부

(1) 민법 제750조

(2) 특허법원 판례

- 1) “독점적 통상실시권을 부여하는 계약이 체결된 경우 특허권자는 계약상 실시권자 외의 제3자에게 실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하고, 실시권자는 시장에서 해당 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가진다.
- 2) 그로 인해 독점적 통상실시권자는 비독점적 통상실시권자와 달리 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 침해하는 제3자에 대하여 그 침해로 인한 손해배상을 청구할 수 있게 된다.”
- (3) 사안의 경우: 민법상 손해배상청구권 행사는 가능(제3자 채권침해를 구성)

4. 사안의 해결

특허법상 손해배상청구권 행사는 불가/ 민법상 제3자 채권침해로 인한 손해배상청구권 행사 가능 (+특허권자가 갖는 특허법상 손해배상청구권을 대위행사는 가능할 것이지만, 실익은 낮음)

(3) 戊는 무단으로 13종의 개별 원액을 국내에서 생산하여 이를 甲이 특허출원 및 등록을 하지 않은 A국에 수출하였고, 이를 수입한 A국적의 a는 A국에서 이를 혼합하여 이 사건 특허발명에 속하는 조성물을 생산하였다. 戊가 甲의 특허권을 직접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)

III 설문(3)

1. 문제의 소재

戊의 수출행위 자체는 특허법상 실시가 아니므로 침해가 아니다(法2(3)).

다만 개별 원액의 국내 생산이 특허발명의 실시로 취급될 수 있는 것인지 문제된다.

2. 물건발명에 관한 판례

(1) 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙

- ① “물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치고(특허권의 속지주의 원칙),
- ② 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 물건이 특허권을 침해하는 물건에 해당하려면 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 그 물건에 그대로 포함되어 있어야 한다(구성요소 완비의 원칙).”

(2) 국내에서 특허제품이 생산된 것과 같이 보는 경우(2019다222782)

- ① “국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ② 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, ③ 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.”

(3) 엄격한 판단(2025다202970)

“이는 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.”

3. 사안의 해결

(1) 물건특허 침해 여부

- ① 개별 원액은 a에게 수출되어 마지막 혼합단계가 예정되어 있다. ② 따라서 개별 원액의 생산만으로도 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품의 생산으로 볼 수 있고 혼합단계가 극히 사소하거나 간단하여 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 국내에서 특허발명이 생산된 것으로 보아 물건특허의 직접침해를 구성하게 된다. ③ 만약 그렇지 않다면 직접침해를 구성하지 않게 된다.

(2) 방법특허 침해 여부

戊는 개별 원액을 혼합하여 조성물을 제조하는 공정을 실시하고 있지 않으므로 구성요소 완비의 원칙상 직접침해를 구성하지 않는다.

(4) 위 (3)의 지문에서 戊가 甲의 특허권을 간접침해하는지 여부에 대해 논하시오. (5점)

IV. 설문(4)

1. 간접침해 의의 및 취지(判例)

2. 직접침해 전제성

(1) 판례

“法127(1)에서 말하는 ‘생산’이란 국내생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.”

(2) 검토(2014다42110)

“특허권의 속지주의 원칙상 물건발명에 관한 특허권자가 가지는 독점적인 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면” 판례는 타당하다.

3. 사안의 해결

(1) 물건특허 간접침해 여부

① 개별 원액 생산이 직접침해를 구성한다면, 개별 원액 중 적어도 일부가 특허발명의 전용품에 해당하는 경우 개별 원액 생산은 간접침해에도 해당한다. ② 개별 원액 생산이 직접침해를 구성하지 않는다면, 그 중 적어도 일부가 전용품에 해당하더라도 간접침해에 해당하지 않게 된다.

(2) 방법특허 간접침해 여부

최종적인 조성물의 제조공정(방법발명의 실시)은 국외에서 이루어지므로, 전 단계의 개별 원액 생산이 국내에서 이루어지더라도 간접침해에 해당하지 않는다.

[문제 - 2]

甲이 출원하여 등록받은 이 사건 특허발명은 ‘생물학적 활성 화합물과 컨쥬게이팅되는 잔기를 갖는 폴리알킬렌 글리콜’이라는 명칭의 발명이다. 이 사건 특허발명은 식품의약품안전처장이 기허가한 의약품의 유효성분인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 공유결합하여 폐길화(PEGylation)한 것인데, 인터페론베타-1a는 단백질 의약품질로 체내에서 활성을 가지며 비정상적인 면역작용을 조절함으로써 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가진다. 한편, 폴리에틸렌글리콜은 혈액 중의 짧은 반감기, 면역원성 및 항원성 유발과 같은 단백질 의약품질의 단점을 보완하기 위하여 단백질 의약품질에 결합되는 것으로 그 자체만으로는 체내에서 활성을 가지지 않는다. 이 사건 특허발명과 관련된 이 사건 의약품인 ‘폴리베타’는 기허가 의약품과 동일한 효능·효과인 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 가지면서도 폐길화함으로써 인터페론베타-1a의 혈액 중 평균체류시간 및 반감기를 증가시킨 의약품이다. 甲은, 식품의약품안전처장으로부터 ‘폴리베타’의 수입품목허가를 받는 데 장기간이 소요되었다는 이유로, 그 실시할 수 없었던 기간만큼 이 사건 특허권의 존속기간 연장등록출원을 하였다.

위 지문을 토대로 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 특허권의 존속기간 연장등록출원제도를 설명한 후, 甲의 이 사건 특허권의 존속기간 연장등록출원에 대해 특허청은 어떠한 결정을 해야 하는지 논하시오. (10점)

(2) 乙은 甲의 ‘폴리베타’와 비교할 때 ‘숙신산염’에서 ‘푸마르산염’으로 변경한 ‘염 변경 의약품’인 ‘폴리JK’를 국내에서 생산하여 판매하였다. 푸마르산염과 숙신산염의 성질을 보면 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없으며, 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있으므로, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있다. 이 경우 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 乙의 ‘폴리JK’의 생산에 미치는지 논하시오. (단, 본 물음에서는 이 사건 특허권의 존속기간이 연장되었다고 가정하고, 특허권 존속기간 연장등록의 타당성, 의약품과 염의 실제 존부 및 효능에 대해서는 다루지 않는다.) (10점)

설문(1)과 (2)에서 각각 대법원 판례를 하나씩 물어보고 있습니다. 대부분 준비가 잘 되어 있는 판례들이었으므로 해결함에 있어 어렵지 않았을 것으로 보입니다.

(1) 특허권의 존속기간 연장등록출원제도를 설명한 후, 甲의 이 사건 특허권의 존속기간 연장등록출원에 대해 특허청은 어떠한 결정을 해야 하는지 논하시오. (10점)

I. 설문(1)

1. 특허권의 존속기간 연장등록출원제도

- (1) 문제의 소재: 존속기간연장제도에는 허가등에 따른 연장과 등록지연에 따른 연장제도가 존재
- (2) 의의(제89조)
- (3) 판례가 실시한 취지
- (4) 요건 및 절차 등

2. 특허청의 결정

(1) 시행령 제7조

(2) '약효'의 해석 判例

“令7에서 말하는 '약효'는 특정 질환명·증상명을 기준으로 하는 품목허가 대상으로서의 '효능·효과'를 의미한다고 볼 수 있다.”

(3) '약효를 나타내는 활성부분'의 해석 判例

“약효'는 질환·증상명을 기준으로 하는 '효능·효과'를 의미하므로, '약효를 나타내는 활성부분'은 '인체 내 세포 등에 작용하여 품목허가상 효능·효과를 발현하는 부분'으로 해석하는 것이 합리적이다.”

(4) 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 경우 判例

“기허가된 의약품의 공지된 활성부분이 발현하는 효능·효과의 정도에 영향을 미치기 위하여 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 의약품 발명은 특허권 존속기간 연장대상이 되는 발명이라고 보기 어렵다.”

(5) 검토

품목허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명에 한하여 이를 구제하도록 정하고 있는 존속기간 연장제도의 취지 및 목적에 비추어, 판례는 타당하다.

(6) 사안의 경우

1) 신물질 해당 여부

- ① 기허가된 인터페론베타-1a의 약효는 재발성 다발성 경화증의 치료효과로 파악할 수 있다.
- ② 甲이 허가등을 받은 것은 인터페론베타-1a에 PEG를 공유결합하여 폐길화한 것이고, 이에 따른 약효 역시 재발성 다발성 경화증의 치료효과로 동일하다.
- ③ 여기서, 甲이 허가등을 받은 조성물에서 약효를 나타내는 활성부분은 인터페론베타-1a에 해당하고 이는 기허가된 의약품과 동일하므로, 甲이 허가등을 받은 조성물은 신물질로 볼 수 없다.

2) 소결

- ① 기허가된 인터페론베타-1a의 효능·효과의 정도에 영향을 미치기 위해 자체로 활성을 가지지 않는 PEG를 부가한 甲의 발명은 존속기간 연장대상이 아니다. ② 따라서 甲의 출원에는 法91(1) 거절이유가 있으므로, 특허청은 이 사건 연장등록출원에 대해 거절결정을 해야 한다.

(2) 乙은 甲의 ‘폴리베타’와 비교할 때 ‘숙신산염’에서 ‘푸마르산염’으로 변경한 ‘염 변경 의약품’인 ‘폴리JK’를 국내에서 생산하여 판매하였다. 푸마르산염과 숙신산염의 성질을 보면 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없으며, 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있으므로, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있다. 이 경우 존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력이 乙의 ‘폴리JK’의 생산에 미치는지 논하시오. (단, 본 물음에서는 이 사건 특허권의 존속기간이 연장되었다고 가정하고, 특허권 존속기간 연장등록의 타당성, 의약품과 염의 실제 존부 및 효능에 대해서는 다루지 않는다.) (10점)

II. 설문(2)

1. 침해 의의 및 성립요건(제94조)

2. 제95조 의의 및 취지

3. 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위

(1) 학설 - 주성분설, 유효성분설, 품목설 등

(2) 특허법원의 견해 - 허가된 품목을 중심으로 판단(2016나1929)

(3) 대법원의 견해 - 유효성분, 치료효과 및 용도를 중심으로 판단

① 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

② 특허권자가 품목허가를 받은 의약품과 침해제품이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 통상의 기술자라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.(2017다245798)

(4) 검토

法95는 “존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다”는 점에서 판례는 타당하다.

4. 사안의 해결

① 폴리JK는 폴리베타와 비교할 때 ‘숙신산염’에서 ‘푸마르산염’으로 변경한 ‘염 변경 의약품’이다.

② 푸마르산염과 숙신산염의 성질을 보면 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없으며, 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있으므로, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있다.

③ 따라서 존속기간이 연장된 이 사건 특허발명의 효력은 乙의 폴리JK의 생산에 미친다.

[문제 - 3]

甲은 발명 X에 대해 청구범위를 제1항 내지 제5항으로 구성하여 2024년 10월 11일 한국 특허청에 특허출원 하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 청구항 제2항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는다는 이유로 의견제출통지서를 받았으나 이에 대해 아무런 대응을 하지 아니하였고, 의견서 제출 기간이 경과하였다. 심사관은 2025년 7월 4일 특허거절결정을 하였고, 甲은 2025년 7월 7일 특허거절결정등본을 송달 받았다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

1) 甲은 의견서 제출 기간이 경과된 후 청구항 제2항을 취하하는 내용의 출원취하서를 특허청에 제출하였으나, 특허청장은 이를 반려하였다. 특허청장의 처분이 적법한지 논하시오.

2) 특허거절결정등본을 송달 받은 甲이 등록받기 위해 취할 수 있는 특허법상의 조치를 논하시오.

(2) 심사관은 청구항 제1항 내지 제5항 모두 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다며 의견제출통지서를 발송하였다. 甲은 거절이유를 극복하기 위해 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다고 특허거절결정을 하였다. 甲은 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 甲에게 의견제출의 기회를 부여하지 아니하고 “청구항 제1항 및 제2항은 진보성이 인정되지만, 청구항 제3항 내지 제5항은 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다”며 청구를 기각하는 심결을 하였다. 특허심판원의 심결이 적법한지 논하시오. (6점)

(3) 甲은 발명 X에 대해 특허등록을 받은 후 특허권 지분 50%를 乙에게 이전하였다. 특허권 지분을 이전한 후 甲은 乙의 동의 없이 대한민국 국적의 A사에게 발명 X의 생산을 의뢰하였고, A사는 발명 X를 생산하여 甲에게 납품하였다. 이러한 사실을 알게 된 乙이 취할 수 있는 법적 조치에 대하여 논하시오. (14점)

설문(1)과 (2)는 아주 평이했습니다. 설문(3)이 그나마 배점이 커서 고민할 수 있겠지만, 기관대행설 성립 여부와, 공유물분할청구권 논점을 바탕으로 배점을 채울 수 있는 문제였습니다.

(1) 甲은 청구항 제2항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는다는 이유로 의견제출통지서를 받았으나 이에 대해 아무런 대응을 하지 아니하였고, 의견서 제출 기간이 경과하였다. 심사관은 2025년 7월 4일 특허거절결정을 하였고, 甲은 2025년 7월 7일 특허거절결정등본을 송달 받았다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

1) 甲은 의견서 제출 기간이 경과된 후 청구항 제2항을 취하하는 내용의 출원취하서를 특허청에 제출하였으나, 특허청장은 이를 반려하였다. 특허청장의 처분이 적법한지 논하시오.

2) 특허거절결정등본을 송달 받은 甲이 등록받기 위해 취할 수 있는 특허법상의 조치를 논하시오.

I. 설문(1) - 1)

1. 출원의 일부취하서의 취급

(1) 문제의 소재

출원의 취하는 출원 전체를 소급소멸시키는 행위이므로, 일부 청구항에 허용할 것인지 문제된다.

(2) 判例(2001후1044)

“보정기간 경과 후에도 출원의 일부 취하를 허용하는 것은 출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에도 반하므로 출원인이 출원의 일부 취하라는 이름의 서류를 제출하였다고 하더라도 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이라면 보정과 마찬가지로 보아야 한다.”

(3) 검토

“특허법에는 보정이라는 제도를 두고 있을 뿐 특허결정이 되기 전에 특허출원의 일부를 취하할 수 있다고 규정해 놓은 바 없으므로” 판례는 타당하다.

(4) 사안의 경우

청구항 2에 관한 출원취하는 사실상 청구항 2를 삭제하는 보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것으로, 보정과 마찬가지로 보아야 한다.

2. 보정기간 경과 후 제출된 보정서의 취급

(1) 시행규칙 제11조

(2) 사안의 경우

출원취하서는 보정서와 같이 취급해야 하는데, 의견서 제출기간이 경과한 후 제출되었으므로, 특허청장은 이를 반려해야 한다. 따라서 특허청장의 처분은 적법하다.

II. 설문(1) - 2)

1. 재심사청구(제67조의2)

2. 거절결정불복심판(제132조의17)

3. 분할출원(제52조)

4. 기타 조치 - 국내우선권주장출원(제55조) / 취하 후 재출원 / 심판 기각 시 분리출원

(2) 심사관은 청구항 제1항 내지 제5항 모두 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다면 의견제출통지서를 발송하였다. 甲은 거절이유를 극복하기 위해 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 심사관은 거절이유가 해소되지 않았다고 특허거절결정을 하였다. 甲은 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 甲에게 의견제출의 기회를 부여하지 아니하고 “청구항 제1항 및 제2항은 진보성이 인정되지만, 청구항 제3항 내지 제5항은 인용발명 Y에 비하여 진보성이 인정되지 않는다”며 청구를 기각하는 심결을 하였다. 특허심판원의 심결이 적법한지 논하시오. (6점)

III. 설문(2)

1. 제170조 준용 제63조

심사관은 특허출원에 대하여 거절결정 하려는 경우 원칙적으로 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 의견제출기회를 주어야 한다. 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 法63를 준용한다(法170①). 法170①에서 준용하는 法63는 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다(法170②).

2. 법적 성격 判例(2015후2341)

“위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.”

3. 주된 취지가 거절결정의 이유와 부합하는 경우 判例(2006후329)

“거절결정불복심판 기각심결 이유가 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에게까지 출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다.”

4. 출원일체의 원칙 判例

“청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 한다.”(2008후934)

5. 사안의 해결

- ① 기각심결의 주된 취지는 청구항 3 내지 5가 인용발명 Y에 의해 진보성이 부정된다는 점인데, 심사절차에서도 청구항 1 내지 5가 인용발명 Y에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정이 있었다. ② 따라서 기각심결의 주된취지가 거절결정의 이유와 부합한다.
- ③ 또한, 청구항 3 내지 5의 거절이유가 있는 이상 청구항 1 및 2의 진보성이 있더라도 출원 전체가 거절되어야 하는 것이므로, 특허심판원의 기각심결은 적법하다.

(3) 甲은 발명 X에 대해 특허등록을 받은 후 특허권 지분 50%를 乙에게 이전하였다. 특허권 지분을 이전한 후 甲은 乙의 동의 없이 대한민국 국적의 A사에게 발명 X의 생산을 의뢰하였고, A사는 발명 X를 생산하여 甲에게 납품하였다. 이러한 사실을 알게 된 乙이 취할 수 있는 법적 조치에 대하여 논하시오. (14점)

IV. 설문(3)

1. 문제의 소재

甲과 乙은 공유특허권자들이므로 甲이 乙의 동의를 받지 아니하고 A에게 의뢰한 이상, A를 실시권자로 볼 수는 없다. 다만 기관대행설에 의해 A사의 실시를 甲의 실시로 취급할 것인지 살핀다.

2. 기관대행설

(1) 일반

특허권자 등이 제3자와 실시계약을 맺고 제3자는 특허권자 등의 감독을 받으며 생산된 물건 전량을 특허권자 등에게 인도하는 경우 제3자의 실시는 특허권자 등의 실시로 볼 수 있다.

(2) 기관대행설이 성립하는 경우

1) 일반

甲은 발명 X의 생산에 관해 A사와 실시계약을 맺은 것으로 볼 수 있다. 만약 A사가 발명 X를 생산하여 전량을 甲에게 납품하였고 이러한 과정에서 甲이 A사를 감독하였다면, A사의 실시는 甲의 실시로 취급된다.

2) 甲에 대한 조치 - 불가

① 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다(法99③).

② 따라서 기관대행설이 성립하여 甲이 발명 X를 실시한 것으로 취급되는 경우, 특약이 없는 한 乙은 A사에게 취할 수 있는 조치가 없다.

(3) 기관대행설이 성립하지 않는 경우

1) 일반

만약 A사가 발명 X를 생산하여 甲에게 전량을 납품하지 않거나 이 과정에서 甲이 감독하지 않은 경우 기관대행설이 성립하지 않고, 발명 X의 생산은 A사의 실시로 취급된다.

2) A에 대한 조치 - 민사적 조치

침해금지청구권(乙이 단독행사 가능), 손해배상청구권(乙이 자신의 지분비율 내에서 행사 가능), 신용회복청구권, 부당이득반환청구권 등

3) A에 대한 조치 - 형사적 조치

침해죄 고소, 몰수, 양벌규정 등

3. 공유물분할청구

(1) 민법 제268조제1항 - 공유물분할청구권

(2) 특허권 공유의 법적성질

(3) 특허법상 공유물분할청구권의 인정가부

1) 제99조 제2항 및 제4항의 취지 判例

“공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 타공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 타공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다.”

2) 공유물분할청구권의 인정가부 判例

“공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 法99②④에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다.”(2013다41578)

3) 검토

민법의 일반규정이 특허권의 공유에 적용되는 점, 타공유자의 동의가 없는 경우 공유관계를 탈피하기 위한 수단으로 공유물분할청구권이 인정되어야 하는 점을 고려할 때, 판례는 타당하다.

(4) 사안의 경우

乙은 甲을 상대로 공유물분할청구권을 행사함으로써 공유관계를 탈피할 수 있을 것이다.

[문제 - 4]

甲, 乙 및 丙은 대학교 동기로서, 공동으로 ‘브로콜리 줄기에서 천연물 X를 추출하는 방법’(이하, ‘발명 Y’라 함)을 발명하기로 하였다. 甲은 관련 선행 논문을 제시하여 아이디어만을 제공하고, 연구에 필요한 설비 및 자금을 지원하였다. 乙은 천연물 X를 추출하는 방법에 관한 아이디어를 제시하고 구체적인 실험을 통해 발명 Y를 완성하였다. 丙 역시 다양한 아이디어를 제공하고 실제 실험을 통해 발명 Y를 구체화하고 완성하는데 기여하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲과 丙은 乙 몰래 발명 Y에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 대한민국 국적의 A사에 이전하였다. A사는 특허출원서에 甲과 丙을 발명자로 기재하고 2024년 11월 4일 한국 특허청에 특허출원하였다. 그 후 乙은 甲과 丙이 A사에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하여 발명 Y가 특허출원된 사실을 알게 되었다. 乙이 A사 및 특허출원에 대해 취할 수 있는 조치를 논하십시오. (14점)

(2) 甲, 乙 및 丙은 서로 간의 합의를 통해 甲이 발명 Y를 단독으로 특허출원하게 되었다. 발명 Y가 특허등록된 후 甲은 대한민국 국적의 B사에 특허권에 대한 유상의 통상실시권을 설정해 주었다. 그 후, B사의 연구원은 우연히 미국 국적의 C사가 발명 Y와 실질적으로 동일한 발명 Y'를 C사 카탈로그에 기재하여 발명 Y의 특허출원일 전에 반포하였다는 사실을 알게 되었다. B사가 甲의 특허에 대해 특허심판원에 취할 수 있는 조치를 논하십시오. (6점)

乙과 丙은 발명자이므로 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 귀속주체가 되는데, A사가 발명자를 甲과 丙으로 기재하여 출원하였으므로, 1) 발명자를 잘못 기재한쟁점 및 2) 출원인이 무권리자인쟁점이 있게 됩니다. 선결적으로, 발명자가 누구인지부터 판단해주어야 합니다.

설문(1)에서 1) 공동발명자 판단, 2) 출원에 대한 조치, 3) 발명자 오기재에 대한 조치(없음)를 비슷한 비중으로 적어주는 것이 중요하다고 판단됩니다.

(1) 甲과 丙은 乙 몰래 발명 Y에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 대한민국 국적의 A사에 이전하였다. A사는 특허출원서에 甲과 丙을 발명자로 기재하고 2024년 11월 4일 한국 특허청에 특허출원하였다. 그 후 乙은 甲과 丙이 A사에 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하여 발명 Y가 특허출원된 사실을 알게 되었다. 乙이 A사 및 특허출원에 대해 취할 수 있는 조치를 논하시오. (14점)

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 발명 Y의 공동발명자 판단

(1) 제33조제2항

(2) 공동발명 성립요건

1) 공동발명자가 되기 위한 요건 判例(2011다67705)

“공동발명자가 되기 위해서는 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 발명의 목적·효과를 달성하기 위한 구체적 수단과 방법의 제공 또는 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.”

2) 공동발명자가 아닌 경우 判例(2011다67705)

“① 기본적인 과제·아이디어만을 제공하였거나 ② 연구자를 일반적으로 관리하고 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 ③ 자금 등을 제공하여 발명의 완성을 후원하였을 뿐인 정도에 그치는 경우 공동발명자로 볼 수 없다.”

(3) 사안의 경우

① 甲은 관련 선행 논문을 제시하여 아이디어만을 제공하고, 연구에 필요한 설비 및 자금을 지원하였을 뿐이므로, 공동발명자로 볼 수 없다.

② 乙은 천연물 X를 추출하는 방법에 관한 아이디어를 제시하고 구체적인 실험을 통해 발명 Y를 완성하였으므로, 공동발명자로 볼 수 있다.

③ 丙 역시 다양한 아이디어를 제공하고 실제 실험을 통해 발명 Y를 구체화하고 완성하는데 기여하였으므로, 공동발명자로 볼 수 있다.

④ 따라서, 발명 Y는 乙과 丙의 공동발명에 해당하고, 특허를 받을 수 있는 권리는 乙과 丙에게 원시적으로 귀속한다.

3. 특허출원에 존재하는 거절이유

(1) 제33조

(2) 제44조

(3) 사안의 경우

1) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 乙과 丙의 공유이므로, 甲은 이에 대해 처분할 수 있는 권원이 없다. ② 또한, 丙은 乙의 공유지분에 대해 처분할 수 있는 권원이 없고, 자신의 지분이라도 乙의 동의 없이 처분할 수 없다(法37③). ③ 따라서 발명 Y에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 乙과 丙에게 귀속된 상태로 유지된다.

2) ① 따라서 A사의 특허출원은 무권리자의 출원이므로, 제33조 위반이다. ② 또한, 발명 Y는 乙과 丙이 공유하고 있는데 A사가 출원하였으므로, 제44조 위반에도 해당한다.

4. 심사청구(제59조) 및 정보제공(제63조의2)

5. 정당권리자 출원(제34조)

6. 출원인 명의변경청구 거부

1) 문제의 소재

2) 학설

3) 검토 및 사안

7. 발명자 기재 관련 조치

(1) 발명자를 잘못 기재한 출원의 법적 취급

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 자가 출원한 경우 法33① 본문 위반으로 거절이유·정보제공사유·무효사유에 해당하지만, 발명자 표시가 잘못된 경우는, 거절이유, 정보제공사유 및 무효사유에 해당하지 않는다.

(2) 발명자 정정 신청 거부

출원인 또는 특허권자가 발명자의 기재를 추가하거나 정정하려는 경우 발명자 정정을 신청할 수 있다(施則28). 반대해석상, 출원인 또는 특허권자가 아닌 경우, 발명자 정정을 신청할 수 없다.

(3) 사안의 경우

1) A사의 특허출원서에 발명자가 甲과 丙으로 잘못 기재되어 있지만 이는 거절이유·정보제공사유·무효사유에 해당하지 않는다. 또한, 乙은 출원인이 아니므로 발명자 정정 신청을 할 수 없다. 따라서 乙은 발명자를 잘못 기재한 것과 관련하여 취할 수 있는 조치가 없다.

2) 한편, 乙이 출원인명의변경을 통해 출원인이 되는 경우, 발명자 정정신청을 할 수 있을 것이다.

(2) 甲, 乙 및 丙은 서로 간의 합의를 통해 甲이 발명 Y를 단독으로 특허출원하게 되었다. 발명 Y가 특허등록 된 후 甲은 대한민국 국적의 B사에 특허권에 대한 유상의 통상실시권을 설정해 주었다. 그 후, B사의 연구원은 우연히 미국 국적의 C사가 발명 Y와 실질적으로 동일한 발명 Y'를 C사 카탈로그에 기재하여 발명 Y의 특허출원일 전에 반포하였다는 사실을 알게 되었다. B사가 甲의 특허에 대해 특허심판원에 취할 수 있는 조치를 논하시오. (6점)

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - 신규성 무효사유 존재

2. 특허무효심판의 청구인 적격(제133조제1항) - 이해관계 판단 법리

3. 실시권자의 이해관계 인정 여부

(1) 종래 판례

(2) 최근 판례

“이해관계인에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.”

(3) 검토

(4) 사안의 경우

B사는 유상의 통상실시권자이지만, 이러한 사정만으로 이해관계를 부정할 수는 없다. 甲의 특허가 소멸하는 경우 B사는 더 이상 실시료를 지급하지 않아도 되는 법률상 이익을 얻게 되므로 甲의 특허의 소멸에 직접적·현실적인 이해관계가 있다. B사의 무효심판 이해관계는 인정된다.

4. 사안의 해결

B사는 甲의 특허에 대해 특허심판원에 특허무효심판을 청구할 수 있다.